

1500140-27.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... munição e a absolvição em relação ao tráfico, pois ele não sabia de fato sobre as drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, com os consectários legais.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500140-27.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500140-27.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026107/2022 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 22705492 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2026107 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO OTAVIO DE MACEDO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de LUIZ REZENDE DA SILVA e MAURICIO OTAVIO DE MACEDO como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo consta na denúncia (fls. 134-136), no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 13:30 horas, na Rua Laurindo de Oliveira, nº 139, Vila Boa Esperança, nesta cidade e comarca Capão Bonito, LUIZ e MAURÍCIO, guardavam e tinham em depósito drogas, consistentes em 02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1.095,09 gramas; 03 (três) outras porções de maconha, pesando 179,68 gramas; 40 (quarenta) pedras de crack, com peso de 18,7 gramas; e 01 (uma) porção de cocaína, de 6,93 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (FATO 01). Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, LUIZ e MAURÍCIO possuíam e mantinham sob sua guarda uma munição, calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior e dependência de sua residência (FATO 02).

De acordo com o Ministério Público, a Polícia Civil recebeu informação de que os réus estariam promovendo o tráfico de drogas no endereço acima referido. De fato, em campanhas pelas imediações, investigadores notaram intensa movimentação de pessoas e atos típicos de tráfico. Na data em questão, os investigadores viram um indivíduo se aproximar da casa e receber algo de MAURÍCIO. Desse modo, ante a fundada suspeita da mercância ilícita, os policiais decidiram abordá-lo, com quem encontraram 07 porções de crack embaladas individualmente e R\$ 66,00 (sessenta e seis reais).

Em seguida, os policiais ingressaram na casa e LUIZ tentou fugir, mas foi contido. Realizadas buscas, foram localizados os demais entorpecentes descritos no "FATO 01" e a munição no "FATO 02", além de vários microtubos vazios e objetos de origem não comprovada.

Considerando as circunstâncias do caso, notadamente as denúncias pretéritas e quantidade de droga apreendida, os réus foram presos em flagrante.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 137-139, seguindo-se a regular citação dos réus (fls. 153, MAURÍCIO e fls. 155, LUIZ), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 200, LUIZ e fls. 210, MAURÍCIO).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos pelo delito de tráfico de drogas e absolvição de ambos em relação à posse da munição. A Defesa de MAURÍCIO requereu a absolvição pelo delito de posse de munição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da confissão e a fixação da pena no mínimo legal.

A seu turno, a Defesa de LUIZ requereu a absolvição pelo delito de posse de munição e a absolvição em relação ao tráfico, pois ele não sabia de fato sobre as drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, com os consectários legais.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido. Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes (FATO 1)

A materialidade da conduta imputada aos réus encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 19-28), auto de exibição e apreensão (fls. 29-32), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 165-176) positivo para maconha e cocaína e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que na fase policial, o réu LUIZ disse que: já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas; não tem o

conhecimento de que seu filho estava armazenando ou realizando o comércio de drogas em casa; não tem mais nada a dizer em sua defesa (fls. 07).

Interrogado em juízo disse que: nega seu envolvimento com o tráfico; não tinha ciência de que seu filho estava traficando; sequer sabia que MAURÍCIO fazia uso de entorpecentes; tinha acabado de chegar na casa, vindo da chácara em que cria animais; MAURÍCIO era quem dormia no colchão embaixo do qual foram encontradas as drogas.

MAURÍCIO afirmou que: já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas; sobre os fatos informa que são verdadeiros, pois realmente estava realizando a venda de drogas em sua casa; ficou desempregado recentemente e por necessidade teve que vender drogas para sua sobrevivência; as drogas são todas suas; seu pai não tem ciência de que estava traficando e armazenando em sua casa tais substâncias; em relação ao projétil de arma de fogo, iria fazer um pingente e no tocante aos objetos que não são subtraídos e todos lhe pertencem (fls. 09). Interrogado em juízo disse que: LUIZ é seu pai biológico; a "mercadoria" que os policiais acharam é do depoente; pegou a "mercadoria" para "fazer um giro" de dinheiro; o pai do depoente não sabia das drogas.

A testemunha, Silvio Almeida de Oliveira, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: na data em questão, se encontrava em serviço no município de Capão Bonito, onde tem atuado na repressão ao tráfico de drogas; há dias realizavam diligências, a fim de apurar denúncia de comércio de drogas por parte do investigado apelidado "mau mau"; importante destacar que em outras oportunidades sua equipe já tinha cumprido mandado de busca no seu endereço antigo, onde localizaram expressiva quantidade de drogas, resultando em sua prisão em flagrante; as denúncias desta vez eram no mesmo sentido, ou seja, que "Maumau" e seu pai estariam realizando a venda de substância entorpecente em seu novo endereço, qual seja a Rua Laurindo de Oliveira, 139 - Vila Boa Esperança; a partir disso, iniciaram as campanhas, a fim de verificar se elas procediam; notaram uma grande movimentação de pessoas no local, incluindo aquelas já conhecidas por serem usuárias de drogas; essas diligências foram realizadas por diversos dias e horários diferentes a uma distância segura para não serem notados; o investigado "Maumau" e seu pai foram vistos por diversas vezes em frente à residência aparentemente entregando algo a pessoas que ao final se retiravam rapidamente, aparentando realmente se tratar de um ponto de drogas, vulgarmente conhecida pela expressão "biqueira"; considerando tal movimentação aliada ao histórico criminal do investigado, resolveram realizar as observações a uma distância mais próxima, para que, se necessário, fosse realizada a abordagem; após alguns minutos, notaram que um motoqueiro se aproximou do investigado "Maumau" em frente a sua residência, oportunidade na qual recebeu alguma coisa e em seguida deixou o local, da mesma forma que havíamos constatado nos dias anteriores; havendo fortes indícios no sentido de que "Maumau" estaria realizando a venda de drogas, decidiram pela sua abordagem; em revista pessoal, encontraram com ele 7 porções de droga tipo "crack" embaladas individualmente e prontas para a venda, bem como a quantia de R\$ 66,00; indagado sobre os fatos ele admitiu que estaria fazendo a venda de drogas pelo local, inclusive admitindo que no interior da casa havia mais entorpecentes; adentraram no imóvel; encontraram seu pai, LUIZ REZENDE DA SILVA, que inclusive tentou fugir da sua equipe; em vistoria pelo imóvel encontraram: 2 tijolos de maconha, 31 pedras de "crack" embaladas individualmente da mesma forma daquelas 7 encontradas com o investigado "Maumau"; uma munição de calibre 38, 01 microtubo contendo cocaína, uma porção maior de droga tipo "crack", 05 porções de maconha (duas em tablete, duas em um saco plástico e outra já fracionada para o uso, vários microtubos novos que supostamente seriam utilizados para acondicionar drogas, além de diversos objetos de origem não comprovadas como celulares, relógios, máquinas de cortar cabelo, carteira, televisão, etc., que podem ser de eventuais vítimas, considerando que usuários costumam trocar tais objetos por entorpecentes; diante dos fatos, conduziram as drogas, valores, objetos e acusados para que a autoridade policial plantonista deliberasse quanto às providências de polícia judiciária. (fls. 03-04).

Em juízo relatou que: uns 30 dias antes do fato haviam surpreendido o MAURÍCIO com

outros 3 indivíduos pela traficância; continuaram as investigações porque chegaram informações de que MAURICIO estaria vendendo drogas no Jardim Boa Esperança; realizaram campanhas diversos dias e constataram movimento típico do tráfico; no dia dos fatos viram um motorista chegar e pegar algo que acreditaram ser entorpecentes; não conseguiram abordar o motoqueiro, mas encontraram com MAURÍCIO 7 porções de crack; na residência encontraram mais entorpecentes; LUIZ estava dentro da residência; as informações diziam que ambos estavam unidos para o tráfico; o entorpecente foi encontrado embaixo de um colchão no quarto em LUIZ dormia; LUIZ já foi preso por tráfico também.

A testemunha, Alessandro Corbage de Sá, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: na data em questão, se encontrava juntamente com meu parceiro Sílvio para realizar diligências com vista à repressão ao tráfico de drogas nesta municipalidade; há dias já realizavam diligências no sentido de averiguar uma denúncia de que o acusado conhecido pela alcunha de "maumau" estaria realizando juntamente com seu pai o comércio de drogas em frente a sua residência na Rua Laurindo de Oliveira, 139 - Vila Boa Esperança; em campanhas visualizaram ambos se aproximarem de pessoas com características de usuários de drogas, ocasião em que entregavam algo a eles; essas observações foram feitas a distância para não serem notados e em dias e horários diversos; na data dos fatos, optaram por realizar essas campanhas a uma distância menor, para que se necessário fosse realizada uma eventual abordagem; após poucos minutos de observação, visualizaram o acusado "maumau", em frente da sua casa, entregar alguma coisa a um motoqueiro, do mesmo modo que tinham observado nos dias anteriores; abordaram o acusado; em revista pessoal, encontraram com ele 07 porções de droga tipo "crack" embaladas individualmente e prontas para a venda, bem como a quantia de R\$ 66,00; ao ser perguntado sobre os fatos, ele admitiu que estaria promovendo o tráfico de drogas pelo local, inclusive afirmando que no interior de sua residência havia uma maior quantidade; adentraram no imóvel e localizaram seu pai que chegou a tentar fugir da equipe, sendo prontamente contido; em busca pelo imóvel, obtiveram sucesso em encontrar 2 tijolos de maconha, 31 pedras de "crack" embaladas individualmente da mesma forma daquelas 7 encontradas com o investigado "maumau"; uma munição de calibre 38, 01 microtubo contendo cocaína, uma porção maior de droga tipo "crack", 05 porções de maconha (duas em tablete, duas em um saco plástico e outra já fracionada para o uso, vários microtubos novos que supostamente seriam utilizados para acondicionar drogas, além de diversos objetos de origem não comprovadas como celulares, relógios, máquinas de cortar cabelo, carteira, televisão, etc., que podem ser de eventuais vítimas, considerando que usuários costumam trocar tais objetos por entorpecentes; conduziram as drogas, valores, objetos e acusados para que a autoridade policial plantonista deliberasse quanto às providências de polícia judiciária. (fls. 05-06).

Em juízo relatou que: chegou ao conhecimento do depoente que os réus estavam traficando entorpecentes no local; o rapaz tinha sido preso poucos dias antes pela mesma prática; realizaram campanhas e concluíram que era muito provável a ocorrência do tráfico; no dia dos fatos um motoqueiro chegou e pegou algo; não conseguiram abordar o motoqueiro; abordaram MAURÍCIO e encontraram crack; houve um tumulto mas adentraram na residência e encontraram mais drogas; durante as campanhas viram ambos os réus entregando algo a supostos usuários; a maior parte do entorpecente estava embaixo do colchão de LUIZ; abordaram inicialmente MAURÍCIO que confirmou a propriedade das drogas encontradas consigo; depois que encontraram as demais, MAURÍCIO assumiu a propriedade de tudo.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer

apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que LUIZ disse que não tinha conhecimento de que seu filho estava realizando a traficância; já MAURÍCIO confessou os crimes e afirmou sua completa responsabilidade pelo fato.

A testemunha e policial civil, Silvio, relatou que realizaram diligências nos arredores da casa dos réus após terem recebido denúncias, visualizando grandes movimentações no local e posteriormente em revista pessoal, após o abordarem em flagrante, encontraram uma quantia da droga apreendida com a pessoa de MAURÍCIO e já dentro da residência encontraram o pai deste, LUIZ, no quarto de quem o restante dos entorpecentes foi apreendido.

A mesma dinâmica foi narrada pela testemunha Alessandro, destacando que MAURÍCIO havia sido preso recentemente pelo tráfico e que, durante as campanhas, ambos os réus foram vistos em atos típicos de comercialização de entorpecentes, corroborando as denúncias recebidas de populares.

Na residência dos réus foram apreendidos 97 supositórios utilizados para a comercialização de cocaína, 1 balança de precisão, 2 outras balanças, diversos sacos plásticos do tipo “sacolê”, também comumente utilizados para embalar entorpecentes, além de diversos outros objetos também compatíveis com a prática costumeira do tráfico de receber pertences como forma de pagamento pela droga, 4 celulares, e dinheiro miúdo, em notas de pequeno valor e moedas (cf. fls. 19-32). Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria, que recai sobre os réus.

2.2 Sobre o delito de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (FATO 02)

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 19-28), auto de exibição e apreensão (fls. 29-32) e pela prova oral colhida em juízo. Nas linhas anteriores consta a referência à prova oral produzida nos autos.

Da análise dos depoimentos e das demais provas dos autos, extrai-se que a munição foi apreendida na casa dos réus. Contudo, trata-se de apenas um cartucho desmuniado. Não se vislumbra efetiva violação ao bem jurídico protegido, carecendo a conduta de tipicidade material.

Portanto, de rigor a absolvição dos réus.

2.3 Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade

Os réus, de forma consciente e espontânea, guardavam e tinham em depósito drogas, consistentes em 02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1.095,09 gramas; 03 (três) outras porções de maconha, pesando 179,68 gramas; 40 (quarenta) pedras de crack,

com peso de 18,7 gramas; e 01 (uma) porção de cocaína, de 6,93 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar no interior e dependência de sua residência, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com isso, está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. Os réus agiram com dolo, nas modalidades cognitivas e volitivas, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, os réus possuem plena capacidade penal e pode ser responsabilizados por seus atos. São penalmente imputáveis e possui condições de compreender a ilicitude de suas condutas e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuíam conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisessem de outra forma. Optaram pela conduta ilícita quando deles era exigível comportamento diverso. Por tais razões, as suas condutas são culpáveis.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação dos réus, LUIZ REZENDE DA SILVA e MAURICIO OTAVIO DE MACEDO, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.4 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.4.1 Dosimetria da pena

a) Para o réu LUIZ REZENDE DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendido maconha, cocaína e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios

brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 02 (dois) tijolos de maconha, pesando mais de 1kg; 03 (três) outras porções de maconha, pesando 179,68 gramas; 40 (quarenta) pedras de crack, com peso de 18,7 gramas; e 01 (uma) porção de cocaína, de 6,93 gramas. O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Nestes autos entende-se que as circunstâncias consideradas negativas merecem valoração maior do que o mínimo de 1/10 acima indicado. Isso porque, quanto à natureza, foram apreendidos os 3 tipos de drogas mais consumidas no país (maconha, cocaína e crack). A simples apreensão de crack, pelas razões indicadas acima, já ensejaria a maior reprovação. Logo, havendo crack associado a outros tipos de entorpecentes implica em aumento da reprimenda.

O mesmo se diga em relação à quantidade de entorpecentes.

Um cigarro de maconha usualmente consome aproximadamente 0,30g da substância, indicam informações de precedentes do Superior Tribunal de Justiça ("É certo que a quantidade de drogas apreendida, 37,8 g [trinta e sete gramas] de maconha", suficiente para a confecção de aproximadamente 133 [cento e trinta e três] cigarros" - HC 251.604/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013; "74,48g - conforme afirmado pelo magistrado de primeiro grau, seria suficiente para a confecção de no mínimo 148 cigarros" - HC 270.612/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard [Desembargadora Convocada Do TJ/SE], Quinta Turma, j. 06/06/2013, DJe 10/06/2013). Somente a quantidade apreendida de maconha (1.274,77g ou 1,274kg), portanto, seria suficiente para confecção de aproximadamente 4.249 cigarros. Cada um desses cigarros comumente é vendido por R\$ 10,00. Isso gera um total de R\$ 42.492,00 ("Conforme relatam os policiais, às fl. 114, R\$ 10,00 (dez reais) é o preço de aquisição de apenas um cigarro" - HC 251.604/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).

Considerando que no presente caso se reconheceram duas circunstâncias negativas (a quantidade e a natureza da substância), com as ponderações supra, acresço ao piso 4/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se constar a circunstância da reincidência (cf. fls. 61-62, - 0001302-64.2015.8.26.0123, 1ª Vara - Foro de Capão Bonito, extinção da pena em 19/05/2021). Contudo, o réu confessou os fatos. Por isso, realizo a compensação e a pena permanece como fixada.

Por fim, na terceira fase, verifica-se a ausência das causas de aumento ou diminuição de pena. Não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas porque o réu é reincidente.

Além disso, da experiência forense advém (de inúmeras oitivas de réus - usuários ou comerciantes de entorpecentes - e de um sem número de testemunhas policiais que se dedicam a investigar o tráfico de entorpecentes e tem familiaridade com as rotinas e valores das drogas) o conhecimento de que o tráfico de entorpecentes no Estado de São Paulo - se não no país - é controlado pela organização criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital. Trata-se de fato notório e negar essa circunstância é negar a realidade. Para que os réus estivessem na posse e na guarda dessa quantidade de entorpecentes é necessário, ao menos, a sua proximidade com membros da organização. Se dela não faz parte, ao menos goza da confiança de seus membros. Essa proximidade com a organização criminosa significa que a colocação do custodiado em liberdade constitui ameaça à ordem e à paz públicas. Sabe-se que um traficante iniciante jamais teria acesso a essa quantidade de entorpecentes. Assim, torno definitiva a pena em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

b) Para o réu MAURÍCIO OTÁVIO DE MACEDO

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base aqui é idêntica a da analisada para o réu Luiz, não se fazendo necessária a repetição. Dessa forma, reconhecidas duas circunstâncias negativas (a quantidade e a natureza da substância), acresço ao piso 4/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo

a pena base em 9 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 65 e 66, do Código Penal, nem daquelas elencadas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual mantenho a pena provisória tal como fixada.

Por fim, na terceira fase, verifica-se a ausência das causas de aumento ou diminuição de pena, pois, apesar de primário, aplica-se as mesmas razões lançadas indicando a proximidade de vínculos com o PCC, como destacado. Torno definitiva a pena em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

2.4.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 9 anos de reclusão), e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado para ambos os réus.

2.4.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso, os réus foram condenados a penas superiores a 4 anos e, portanto, não satisfazem o requisito objetivo para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), nem para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

2.4.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.4.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Recepção. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo.

Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

- a) CONDENAR os réus LUIZ REZENDE DA SILVA e MAURICIO OTAVIO DE MACEDO pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006 (FATO 01), às penas de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 dias-multa, fixados individualmente em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos;
- b) ABSOLVER os réus LUIZ REZENDE DA SILVA e MAURICIO OTAVIO DE MACEDO da acusação de prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03 (FATO 02), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

CONDENO os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. LUIZ é reincidente específico no tráfico. E como assinalado na fundamentação da dosimetria da pena, a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos é indicativo da proximidade dos réus com a criminalidade organizada.

Recomende-se a manutenção da custódia cautelar. Expeçam-se as guias de recolhimento provisório.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 29-32, por serem produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intimem-se os réus para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA